

1500531-87.2022.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Magistrado: Alexandre Torres de Aguiar

Comarca: São Vicente

Foro: Foro de São Vicente

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/07/2022

... se prove o contrário.

Cálculo da Pena - Tráfico de Entorpecentes - Exacerbação da pena-base seguindo os critérios norteadores previstos nos art. 59 do CP em razão da quantidade e a variedade do entorpecente apreendido - Admissibilidade

Nos casos de tráfico de entorpecentes (art. 33, da Lei n. 11.343/06) é perfeitamente admissível a elevação da pena-base com base na ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Vicente

Foro de São Vicente

1ª Vara Criminal

Rua Jacob Emmerich, 1367, São Vicente - SP - cep 11310-906

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500531-87.2022.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500531-87.2022.8.26.0536

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUILHERME CERQUEIRA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Alexandre Torres de Aguiar

Vistos.

GUILHERME CERQUEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 14 da Lei nº 10.826/03 c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, porque, nas circunstâncias de tempo e espaço descritas na denúncia, portava arma de fogo de uso permitido, sendo uma pistola, calibre 765, com número 655275, de marca Ceskaz, desmuniada, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar.

Recebida a denúncia, o réu foi citado e apresentou resposta à acusação.

Durante a instrução processual foram ouvidas as testemunhas arroladas na denúncia e, ao final, foi o réu interrogado.

Encerrada a instrução, as partes ofereceram suas alegações finais.

O Ministério Público requereu a condenação do réu, nos termos da denúncia, diante da prova produzida. Formulou pedidos relativos à fixação da pena e do regime prisional.

A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição do acusado, diante da nulidade da prisão, decorrente de atos investigatórios realizados por guardas municipais, bem como por falta de provas. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena-base em seu mínimo legal e a fixação do regime aberto.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência, pelo auto de prisão em flagrante, pelo auto de exibição e apreensão, pelo laudo pericial realizado na arma, o qual concluiu que esta podia ser utilizada para a realização de disparos, bem como pelos demais elementos constantes dos autos.

A autoria também é certa.

Interrogado em Juízo, o acusado negou a prática do crime descrito na denúncia. Disse que retornava para sua casa, após ter dormido na casa de sua namorada, quando a viatura da guarda civil pediu para que parasse e encostasse sua bicicleta. Contou que foi abordado, revistado e questionado sobre antecedentes criminais, bem como sobre estar sozinho e sobre ter dispensado uma arma. Alegou que os policiais, então, verificaram que possuía antecedentes criminais e acionaram apoio, momento em que foi levado à delegacia para averiguação, sem ser algemado. Disse que, na delegacia, soube ter sido apresentada uma arma e que a propriedade desta lhe foi atribuída. Declarou que sua casa situa-se próximo à Igreja Matriz e estava com sua bicicleta de cor roxa quando abordado. Contou que o local de sua abordagem era próximo a um supermercado, havendo movimentação de transeuntes e também de outras pessoas de bicicleta, mas ninguém mais estava consigo. Não conhecia os guardas que o abordaram e não soube por que motivo eles o prejudicariam. Contou, então, não ter sido questionado sobre a arma no momento de sua abordagem e alegou não ter visto qualquer arma, nem mesmo na delegacia. Disse que sua namorada reside próximo à Igreja Matriz e que sua abordagem ocorreu por volta de 9h30 da manhã. Alegou que um dos guardas municipais que depôs em Juízo não foi o que o abordou, mas, sim, o que chegou ao local depois da abordagem, em apoio. Contou que foi conduzido à delegacia com os guardas que o abordaram inicialmente, sendo que um deles era uma agente de segurança feminina. Alegou que em nenhum momento admitiu aos guardas que portava arma.

Entretanto, a negativa do acusado e a versão por ele apresentada, além de não serem críveis, encontram-se isoladas no contexto probatório.

A testemunha guarda municipal Carlos Aurélio Pereira dos Santos, ouvida sob o crivo do contraditório, relatou que realizava patrulhamento pela Avenida Capitão Mor Aguiar quando transeuntes solicitaram o apoio de sua equipe, informando que um indivíduo trajando camisa branca, usando bicicleta e portando arma, tentou assaltá-los. Declarou que o acusado foi visto evadindo-se e, feito patrulhamento, foi realizada sua abordagem. Esclareceu que, no momento da abordagem, o réu dispensou o armamento, lançando-o ao chão. Consignou que sua guarnição foi quem primeiro abordou o réu e visualizou o réu jogando a arma aos seus pés. Disse que questionou o réu sobre ter abordado pessoas e tentado assaltá-las e ele apenas respondeu "positivo", admitindo que estava com a arma. Relatou que o armamento tratava-se de uma pistola e esta foi recuperada pelo guarda municipal José Estefano, que melhor verificou as características do armamento e o apresentou à Autoridade Policial.

Narrou que os transeuntes que acionaram sua equipe foram qualificados no registro de ocorrência da guarda municipal.

A testemunha guarda municipal José Estefano Rodrigues Simone, ouvida em Juízo, narrou que estava em deslocamento pela Rua Marquês de São Vicente quando sua equipe foi acionada por populares, que noticiaram sobre três indivíduos tentando praticar um assalto. Disse que quando estes indivíduos viram a viatura, separaram-se. Narrou que foi em direção ao réu, que os populares apontaram como sendo o indivíduo que possivelmente estava armado, e foi realizada sua abordagem, sem resistência do acusado. Esclareceu que o réu havia dispensado o armamento, que se constatou que estava com ele, antes de ser abordado. Consignou que a arma apreendida tratava-se de uma pistola de calibre 765, numerada, e guarnecida com carregador, mas não municiada. Relatou que realizou a apreensão da arma, enquanto seu parceiro de farda, GCM Carlos, realizou a busca pessoal no réu. Narrou que os populares que acionaram sua equipe indicaram os indivíduos que tentavam praticar o assalto e apontaram o acusado, que estava pedalando uma bicicleta roxa. Disse que manteve certa distância do réu, diante da suspeita de estar ele armado, e, quando ele ingressou em uma rua, onde havia um mercado, foi realizada a aproximação com a viatura e, então, sua abordagem. Declarou que os outros indivíduos que foram apontados pelos populares conseguiram evadir-se, pois somavam um total de três indivíduos e a equipe policial estava em apenas uma viatura. Consignou que a bicicleta usada pelo réu despertava maior atenção, pois tinha a cor roxa e uma cesta. Afirmou que o armamento foi dispensado pelo réu em via pública, próximo a ele. Narrou que o acusado admitiu, informalmente, que o armamento pertencia a ele, o que constou no registro de ocorrência formulado, mas não forneceu esclarecimentos sobre a origem dela ou sobre os motivos de estar armado. Declarou que os fatos ocorreram entre 9h30min e 10 horas e o local da abordagem situava-se próximo a um mercado. Relatou que duas outras viaturas da GCM estiveram no local em apoio.

Desta forma, restou bem caracterizado o crime descrito na denúncia.

No presente caso, a palavra dos agentes de segurança, que de maneira uniforme e convincente, descreveram com detalhes como ocorreu a abordagem do acusado e a apreensão da arma, não restou abalada.

Não há nos autos qualquer elemento idôneo hábil a retirar a credibilidade dos testemunhos dos agentes de segurança.

Como já se decidiu “é bem sabido que não furta a lei validade aos depoimentos de policiais, tanto que sequer os isenta do compromisso de dizer a verdade, nem os poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, se vierem sonegar a realidade dos acontecimentos. Ao juiz, o que cumpre é conferir a tais declarações o justo e merecido valor, cotejando-as e confrontando-as com os demais elementos de convicção, conferindo-lhes, ou não, segundo seu livre poder de convencimento, o merecido poder de persuasão. Não se compreende, na verdade, seja a atividade policial desprovida de um mínimo de eficiência, de ética, de veracidade a ponto de se arvorar em incriminadora insensata de inocentes. Nem teria sentido conferir a lei determinada tarefa ao agente de segurança para, ao depois, quando ele fosse convocado a prestar contas de sua atuação, negar-lhe valor, aprioristicamente, por preconceituosa admissão de que não diz a verdade” (Apelação criminal nº 112.195-3/1, Santos, Rel. Des. Canguçu de Almeida, em 07/10/1991, 2ª Câmara Criminal).

Aliás, mostra-se “imprescindível salientar que é entendimento pacífico em nossa jurisprudência que o depoimento de policiais responsáveis pela segurança pública, não podem ser desacreditados, em primeiro lugar porque, constitucionalmente, são aptos, como qualquer cidadão a prestar testemunho sob o compromisso da lei. De outra forma, seria incoerente negar a quem tem função de salvaguardar a ordem pública o direito (e o dever) de prestar contas de sua função, justamente quando a cumpre a contento” (TJSP - AP - Rel. Walter Guilherme - j. 10.03.98 - JTJ 214/284).

Ademais, o Supremo Tribunal Federal já teve oportunidade de manifestar-se favoravelmente à validade desses depoimentos. A propósito, registro: "Tóxicos - Tráfico - Prova testemunhal: Depoimento de policiais. A prova testemunhal obtida por depoimento de agente policial não se desclassifica tão-só pela sua condição profissional, na suposição de que tende a demonstrar a validade do trabalho realizado; é preciso evidenciar que ele tenha interesse particular na investigação ou, tal como ocorre com as demais testemunhas, que suas declarações não se harmonizem com outras provas idôneas. Precedente" (STF - 2. T.- HC nº 74.522-9/AC - Rel. Mm. Maurício Correa - DJU 13/12/96, pág. 50.167).

"Prova - Depoimento testemunhal de agentes policiais -Validade. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstra - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF 1a Turma - HC n. 74.608-0/SP - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 11/04/97, pág. 12.189).

No mesmo sentido:

"APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO EVIDENCIAM A NARCOTRAFICÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA ESTABELECIDADA DE MODO INCORRETO. MENORIDADE RELATIVA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. INAPLICABILIDADE DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS. MANUTENÇÃO À MÍNGUA DE PEDIDO NO RECURSO MINISTERIAL. REGIME FECHADO. PROVIMENTO DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

1. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restaram devidamente comprovadas. Substância entorpecente encontrada em poder do réu.

2. Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexiste impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE - Rel. Min. Carlos Ayres Brito - j. 05.09.06; HC 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 18.10.96; HC 70.237 - Rel. Min. Carlos Velloso - RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP - Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze - j. 06.06.13; HC 177.980/BA - Rel. Min. Jorge Mussi - j. 28.06.11; HC 149.540/SP - Rel. Min. Laurita Vaz - j. 12.04.11 e HC 156.586/SP - Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho - j. 27.04.10).

Outrossim, especificamente quanto aos guardas civis, incide a inteligência da Lei n. 13.022/14, que amplia a restrita interpretação que se havia do art. 144, §8º, da Constituição Federal, dando-lhes, dentre outras competências específicas, as funções de colaboração na apuração penal e na defesa da paz social. Logo, as Guardas Municipais (guardas civis) estão investidas na incumbência da garantia da paz social, atuando na prevenção da prática de crimes, podendo, inclusive, atuar de

forma a impedir a sua ocorrência, ou no caso de flagrante, conferir meios para subsidiar a apuração do fato criminoso. Precedentes do STJ (HC 290.371/SP - Rel. Min. Moura Ribeiro - j. 27.05.14; RHC 45.173/SP - Rel. Min. Jorge Mussi - j. 26.05.14 e HC 109.105/SP - Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima - j. 23.02.10).

3. Os indícios são as circunstâncias conhecidas e provadas a partir das quais, mediante um raciocínio lógico, pelo método indutivo, se obtém a conclusão, firme, segura e sólida de outro facto; a indução parte do particular para o geral e, apesar de ser prova indireta, tem a mesma força que a testemunhal, a documental ou outra. Validade da utilização dos indícios como prova da autoria criminosa. Precedentes do STF (AP 470/MG - Pleno - Voto Min. Cezar Peluso - j. 28.08.12 - Revista Trimestral de Jurisprudência - Volume 225 - Tomo II - pág. 1.218/1.220 e AP 470/MG - Pleno - Voto Min. Luiz Fux - j. 28.08.12 - Revista Trimestral de Jurisprudência - Volume 225 - Tomo II - pág. 838/842).

4. Dosimetria da pena estabelecida de modo incorreto. Menoridade relativa. Correção de ofício.

5. Tem-se entendido, corretamente, frise-se, que a conduta social do réu, o concurso de agentes, a quantidade e a natureza da substância entorpecente, a variedade das substâncias entorpecentes, os petrechos utilizados pelo criminoso e as circunstâncias da apreensão da substância entorpecente servem, primacialmente, como amparo probatório para o reconhecimento da dedicação do réu à atividade criminosa. Precedentes do STF (HC 121.057/SP - Rel. Min. Luiz Fux - j. 25.02.14 - DJU 18.03.14; HC 118.380/SP - Rel. Min. Teori Zavaski - j. 04.02.14 - DJU 14.02.14; HC 116.541/ES - Rel. Min. Gilmar Mendes - j. 21.05.2013 - DJE 06.06.13; HC 109.236/SP - Rel. Min. Cármen Lúcia - j. 13.12.11 - DJU 14.23.12). Manutenção à míngua de pedido no recurso Ministerial.

6. O regime inicial de cumprimento de pena para os crimes de tráfico de drogas será o fechado, medida esta estabelecida em perfeita harmonia com o tratamento diferenciado e mais rígido conferido pela própria Constituição Federal aos crimes hediondos e equiparados (art. 5º, XLIII), não cumprindo ao Poder Judiciário analisar a conveniência e a adequação da política criminal do seu tratamento, matéria reservada ao Poder Legislativo, Órgão constitucionalmente competente para tanto.

7. Provimento do recurso do Ministério Público e correção, "ex officio", da dosimetria da pena." (Ap. nº 3003382-41.2013.8.26.0471; Relator(a): Airton Vieira; Comarca: Porto Feliz; Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Extraordinária; Data do julgamento: 01/06/2016; Data de registro: 07/06/2016) (grifo nosso)

"Tráfico de entorpecentes - Agente que mantém em depósito e guarda substância estupefaciente - Desnecessidade de flagrância na prática de oferta gratuita ou de venda - Caracterização

Para a realização do tipo penal previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06, não se exige estado de flagrância na prática de qualquer ato indicativo de oferta gratuita ou de venda da substância entorpecente, uma vez constar dentre os núcleos verbais ali relacionados aqueles de "manter em depósito" e de "guardar".

Tráfico de entorpecentes - Agente que vende substância estupefaciente a policial pensando tratar-se de consumidor - Apreensão que quantidade expressiva de entorpecente por ele guardado - Materialidade e autoria comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é harmônico com o conjunto probatório - Alegação do agente no sentido de ser apenas usuário incompatível com o conjunto probatório e com a quantidade de entorpecente apreendida

Realiza o tipo penal previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06 o agente que vende substância estupefaciente a policial, pensando tratar-se de consumidor. Ainda que assim não fosse, o próprio estado de flagrância na prática de qualquer ato indicativo de oferta gratuita ou de venda da substância entorpecente não é necessário para caracterizar o tráfico, uma vez constar dentre os núcleos verbais ali relacionados aqueles de "manter em depósito" e "guardar". A ulterior alegação de que a substância ilícita se destinaria apenas ao uso próprio não se coaduna com a dinâmica de sua apreensão, devendo ser afastada.

No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os Tribunais

têm deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário.

Cálculo da Pena – Tráfico de Entorpecentes – Exacerbação da pena-base seguindo os critérios norteadores previstos nos art. 59 do CP em razão da quantidade e a variedade do entorpecente apreendido – Admissibilidade

Nos casos de tráfico de entorpecentes (art. 33, da Lei n. 11.343/06) é perfeitamente admissível a elevação da pena-base com base na variedade e qualidade do tóxico apreendido, nos termos do art. 42 da Lei de Tóxicos.

Cálculo da Pena – Tráfico de entorpecentes – Desnecessidade de comprovação de nexos causal entre a conduta do acusado e a circunstância da apreensão ter ocorrido nas imediações de estabelecimento de ensino – Causa de aumento de pena (art. 40, III, da Lei nº 11.343/06) de natureza objetiva – Reconhecimento

Imperioso o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/06 sempre que for constatado que o tráfico de drogas estava sendo praticado nas imediações de estabelecimento de ensino. Em tal situação, torna-se dispensável a comprovação de que o acusado comercializava entorpecentes erigindo diretamente os alunos da escola como público alvo, uma vez cuidar-se de causa de aumento de natureza objetiva.” (Ap. nº 0039706-12.2014.8.26.0224; Relator(a): Grassi Neto; Comarca: Guarulhos; Órgão julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 19/05/2016; Data de registro: 19/05/2016) (grifo nosso)

O esforço da Defesa em desqualificar os depoimentos das testemunhas guardas municipais que realizaram a abordagem do acusado e a apreensão da arma não é suficiente para retirar a força probante deles.

As graves acusações feitas contra os agentes de segurança que efetuaram a prisão em flagrante do réu não vieram acompanhadas de qualquer elemento probatório.

Argumentos genéricos que visam a desprestigiar a Polícia ou a Guarda Municipal como um todo em nada influenciam na prova colhida no presente caso.

Frise-se que os depoimentos colhidos durante a instrução criminal mostram-se coerentes e harmônicos quanto às circunstâncias em que se deu a ação dos agentes de segurança e a localização do armamento, e encontram-se em consonância com as declarações prestadas perante a autoridade policial.

Veja-se que as testemunhas guardas municipais puderam esclarecer em Juízo, de forma pormenorizada e com maior riqueza de detalhes, todas as circunstâncias em que se deu a abordagem do réu e de que forma o armamento foi localizado.

Ambas as testemunhas disseram terem sido acionadas por populares que apontaram o acusado como um indivíduo que estaria tentando assaltá-las, com o uso de arma de fogo, e, por esta razão, foram ao encalço do réu e o abordaram.

Asseveraram que, antes de ser abordado, o acusado dispensou o armamento no chão, em local próximo a ele e as testemunhas ressaltaram que foi o agente José Estefano quem recuperou o armamento, enquanto o agente Carlos Aurelio efetivamente abordava o réu.

Afirmaram que o acusado, informalmente, admitiu o porte da arma de fogo, tendo a testemunha José Estefano consignado que esta declaração informal constou do registro de ocorrência por eles formulado.

Observe-se, neste aspecto, que a testemunha Carlos Aurélio também esclareceu que houve o registro de ocorrência da guarda municipal, documento este em que os

transeuntes que acionaram sua equipe teriam sido, inclusive, qualificados.

Apenas para consignar, eventuais contradições no que pertine a aspectos secundários, conforme apontado pela combativa Defensora, são até normais, dando autenticidade aos relatos, porquanto testemunhas são seres humanos e, como tais, naturalmente suscetíveis a falhas, não sendo tais divergências suficientes para se afirmar que estão mentindo, mormente porque, sobre o fato em si, as narrativas revelam-se uníssonas.

“Pequenas discrepâncias de prova testemunhal explicam-se pelas naturais diferenças de comunicação e pelo fato de terem sido os depoimentos recolhidos em oportunidades diferentes e por pessoas diferentes. (TACRIM-SP-AC nº 162.623 – Rel. Sílvio Lemmi).

De outro lado, a negativa do réu e a versão por ele apresentada não se mostraram críveis, uma vez que não há razão plausível para que os agentes de segurança o incriminassem injustamente.

Dessa forma, não há qualquer dúvida de que o acusado estava efetivamente portando a arma de fogo que foi apreendida.

A potencialidade lesiva da arma foi demonstrada pelo laudo pericial de fls. 75/79, que atestou que o revólver apreendido com o acusado era apto à realização de disparos.

Outrossim, nenhum documento de porte ou registro da arma de fogo apreendida foi apresentado pelo réu.

Finalmente, a nulidade da prova arguida pela Defesa, em razão da ilegalidade da prisão efetuada por guardas municipais, não prospera.

Ao contrário do aduzido pela Defesa, nada há nos autos a indicar que os guardas municipais estivessem no local dos fatos para realizar trabalho investigativo ou qualquer outra conduta privativa de polícia judiciária.

Veja-se que as testemunhas declararam que foram acionadas por transeuntes que comunicaram ter sofrido uma tentativa de assalto e indicaram o acusado como sendo o indivíduo que portava uma arma de fogo.

Motivados pela comunicação feita por populares e diante da fundada suspeita, as testemunhas guardas municipais realizaram a diligência que culminou com a detenção do réu e apreensão da arma de fogo que era portata por ele.

Note-se que os integrantes da guarda municipal, embora tenham como função precípua a proteção do patrimônio municipal, não estão impedidos, tal como qualquer pessoa do povo, de realizar a prisão em flagrante, fazendo cessar prática criminosa que seja por eles presenciada, nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal, conduta esta que não se confunde com usurpação de funções das polícias militar ou civil.

Nesse sentido:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. INCOMPETÊNCIA DOS GUARDAS MUNICIPAIS PARA EFETUAR PRISÃO EM FLAGRANTE. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A primeira parte do art. 301 do Código de Processo Penal autoriza a qualquer do povo prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Desse modo, inexistente ilegalidade na prisão em flagrante realizada por guardas municipais.

Conforme compreensão da Sexta Turma desta Corte Superior, havendo fundada suspeita a configurar situação de flagrante delito, mostra-se lícita a abordagem pessoal feita pela Guarda Civil Municipal, que não atua, nessa hipótese, como polícia investigativa (AgRg no HC n. 667.413/SP, Relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 1º/6/2021, DJe 16/6/2021). Precedentes. No caso vertente, houve a fundada suspeita para a atuação da Guarda Municipal. Desse modo, inexiste ilegalidade na prisão em flagrante realizada.

2. O Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergem elementos suficientemente idôneos de prova a enaltecer a tese de autoria delitiva imputada pelo Parquet ao acusado, a corroborar, assim, a conclusão aposta na motivação do decreto condenatório pelo delito de tráfico. Dessa forma, rever os fundamentos utilizados pela Corte de origem, para decidir pela absolvição do acusado, tendo em vista a ausência de prova para a condenação, ou a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, como requer a parte agravante, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ.

3. Agravo regimental não provido." (AgRg no AREsp n. 2.037.067/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 25/4/2022.)

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. ILICITUDE DAS PROVAS. ATUAÇÃO INVESTIGATIVA DA GUARDA MUNICIPAL. ANULAÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA USO DE DROGAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA MINORANTE NA FRAÇÃO MÁXIMA. ATOS INFRACIONAIS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "A primeira parte do art. 301 do Código de Processo Penal autoriza a qualquer do povo prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Desse modo, inexiste ilegalidade na prisão em flagrante realizada por guardas municipais.

Conforme compreensão da Sexta Turma desta Corte Superior, havendo fundada suspeita a configurar situação de flagrante delito, mostra-se lícita a abordagem pessoal feita pela Guarda Civil Municipal, que não atua, nessa hipótese, como polícia investigativa" (AgRg no HC 667.413/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 1º/6/2021, DJe 16/6/2021).

2. Na espécie, os guardas municipais, em patrulhamento de rotina, avistaram o exato momento em que o agravante realizava a venda de entorpecentes, razão pela qual o prenderam em flagrante.

3. O pleito de desclassificação da conduta de tráfico para a de uso de entorpecente demandaria inevitável revolvimento de matéria fático-probatória, o que se não mostra viável na via estreita do habeas corpus. Precedentes.

4. De acordo com o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, o agente poderá ser beneficiado com a redução de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) da pena, desde que seja primário, portador de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa.

5. A Terceira Seção desta Corte de Justiça tem manifestado o entendimento de que é possível a utilização de atos infracionais para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Precedentes.

6. No caso em tela, não foi reconhecida a incidência da minorante com base na dedicação do paciente à atividade criminosa, tendo em vista a anterior prática de atos infracionais, com observância aos pormenores da situação concreta e respeitando os critérios estabelecidos pelo art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, sendo excluída a possibilidade de aplicação do pretendido redutor.

7. Agravo regimental desprovido." (AgRg no HC n. 703.036/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 14/3/2022.)

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. GUARDAS MUNICIPAIS. BUSCA PESSOAL E PRISÃO EM FLAGRANTE. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Os arts. 932 do Código de Processo Civil CPC c/c o 3º do Código de Processo

Penal CPP, e 34, XI e XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça RISTJ, além do enunciado n. 568 da Súmula desta Corte, permitem ao relator negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com Súmula ou com jurisprudência dominante nos Tribunais Superiores, não importando em cerceamento de defesa ou violação ao princípio da colegialidade, notadamente diante da possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como ocorre no caso, que permite que a matéria seja apreciada pelo Colegiado, afastando eventual vício.

2. A jurisprudência pacífica desta Corte tem admitido a realização de busca pessoal e a prisão em flagrante por guardas municipais, tendo em vista a autorização constante nos artigos 240, § 2º, 244 e 301 do Código de Processo Penal. In casu, o agravante foi surpreendido por guardas municipais quando trazia uma sacola contendo entorpecentes. Ao notar a aproximação, o denunciado tentou empreender fuga, adentrando em vegetação próxima a uma área desabitada, porém terminou detido. Na referida sacola plástica foram encontradas as drogas - 33 porções de maconha (148,44g), 103 de cocaína (133,85g) e 30 pedras de crack.

3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC n. 679.338/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 2/3/2022.)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO. INVERSÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVIABILIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE REALIZADA POR GUARDA MUNICIPAL. ART. 301 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Para se acolher a pretendida absolvição da Agravante, seria necessário reapreciar todo o conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível na via do habeas corpus, pois o Tribunal de origem entendeu que existem provas suficientes para a sua condenação.

2. A primeira parte do art. 301 do Código de Processo Penal autoriza a qualquer do povo prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Desse modo, inexistente ilegalidade na prisão em flagrante realizada por guardas municipais.

3. Havendo fundada suspeita a configurar situação de flagrante delito, mostra-se lícita a abordagem pessoal feita pela Guarda Civil Municipal, que não atua, nessa hipótese, como polícia investigativa.

4. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC n. 695.254/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 4/11/2021.)

Portanto, não há que se falar em ilegalidade da prisão em flagrante do acusado.

Assim, a prova acusatória é robusta e suficiente para uma condenação, como exposto.

Procedente a denúncia, passo, portanto, a dosar a pena.

Atendendo às circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, observo que o réu possui maus antecedentes (certidão de fls. 22), motivo pelo qual aumento a pena-base em 1/6, a qual resta fixada em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa. Considerando a situação econômica do réu, fixo o valor de cada dia-multa no mínimo legal.

Na segunda fase da aplicação da pena, verifico que o acusado é reincidente, conforme certidão criminal de fls. 21, razão pela qual aumento sua pena em 1/6, ficando ela fixada em 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa, no valor já estabelecido.

Verifico, ainda, que o delito foi cometido em ocasião de calamidade pública. Em que pese a vigência somente até 31 de dezembro de 2020 do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, em âmbito federal, verifica-se que o estado de calamidade pública no Estado de São Paulo, decorrente da pandemia do COVID-19, foi reconhecido por meio do Decreto nº 64.879, de 20 de março de 2020, que ainda se encontra em vigência diante de sucessivas

prorrogações. Portanto, em âmbito estadual, mantiveram-se vigentes as normas referentes ao reconhecimento do estado de calamidade pública. A agravante tem caráter objetivo, não se exigindo, portanto, requisito outro adicional que não a mera existência do estado emergencial, a atribuir maior grau de reprovabilidade às condutas ilícitas perpetradas durante sua vigência. De qualquer forma essa circunstância não pode ser ignorada, pois o isolamento social e a quarentena, em razão da pandemia, facilitam a prática do crime. Impõe-se, portanto, o aumento de pena pelo reconhecimento da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal em 1/6, ficando a pena fixada em 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 03 (três) dias de reclusão e pagamento de 14 (catorze) dias-multa, no valor já fixado.

Não há circunstâncias atenuantes a serem reconhecidas.

À míngua de outras causas modificadoras da pena, torno definitiva a reprimenda acima estabelecida.

Fixo o regime fechado como regime inicial do cumprimento da pena, diante da reincidência do acusado, bem como das circunstâncias judiciais que lhe são desfavoráveis.

Não é possível a substituição da pena privativa de liberdade por outra espécie de pena, diante dos maus antecedentes e da reincidência do réu, bem como é incabível o sursis.

Finalmente, não há se cogitar da aplicação imediata do disposto no §2º do artigo 387 do Código de Processo Penal nesta seara, vale dizer, sem elementos concretos a respeito do seu comportamento no cárcere, a recomendar a prudência e o bom senso que a questão relacionada à detração penal seja analisada por primeiro pelo Juízo das Execuções.

A lei a ser utilizada por ocasião da fixação do regime inicial é o Código Penal e não o Código de Processo Penal. A progressão de regime vem, por sua vez, necessariamente regida pela Lei de Execução Penal que, em razão de sua especialidade, tem preponderância sobre as demais, de natureza diversa. Para que seja efetuada a progressão, imprescindível que sejam analisados os respectivos requisitos pelo Juiz natural da causa, que é o do Juízo das Execuções Penais, e não o prolator da sentença.

Nesse sentido:

"Apelação - Tráfico de entorpecentes - Materialidade e autoria bem demonstradas - Testemunho dos agentes policiais, sob o crivo do contraditório, ratificando a prova administrativa - Ré confessa, ademais - Não incidência do § 4º, do art. 33 da Lei 11.343/06, uma vez que não preenchidos os requisitos subjetivos - Precedentes - Pena de multa que se corrige - Mínimo erro material do r. juízo em detrimento da apelante - Regime fechado justificado - Impossibilidade de substituição da física por restritiva de direito - Detração - Matéria afeta ao Juízo das Execuções Criminais - Recurso desprovido, com observação." (TJSP - Ap. Nº 0003591-97.2014.8.26.0577 - 4ª Câmara - Rel. Ivan Sartori - J. 28.04.2015 - grifei)

Deve-se ressaltar, ainda, que a detração neste momento processual causaria a supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu GUILHERME CERQUEIRA, qualificado nos autos, a cumprir a pena de 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 03 (três) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 14 (catorze) dias-multa, fixado o valor do dia-multa no mínimo legal, por infração ao disposto no artigo 14 da Lei nº 10.826/03, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "j",

do Código Penal.

Nego ao réu o direito de apelar desta em liberdade, estando presentes os requisitos para a prisão preventiva. O acusado é reincidente e as circunstâncias judiciais lhe são negativas. A reiteração de condutas criminosas evidencia a dificuldade do réu em aceitar a ordem legal estabelecida, pois não hesita em reiterar a prática delitiva, colocando em maior risco a ordem social.

Finalmente, não há qualquer alteração da situação fática ou jurídica que justifique a reconsideração da decisão que decretou a custódia cautelar no presente feito, mormente no momento em que foi proclamado culpado em primeiro grau de jurisdição.

Portanto, verifico que ainda estão presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo de rigor manter a prisão preventiva, cumprindo-se, outrossim, o disposto no parágrafo único do artigo 316 do mesmo diploma legal.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

São Vicente, 01 de julho de 2022.

ALEXANDRE TORRES DE AGUIAR
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA